

1000398-89.2020.8.26.0660

Classe: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz Singular

Assunto: Calúnia

Magistrado: PEDRO HENRIQUE ANTUNES MOTTA GOMES

Comarca: Viradouro

Foro: Foro de Viradouro

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 02/11/2022

... demonstrar a materialidade do crime de tráfico de maconha com uma fotografia de uma erva. E, da mesma forma que o traficante confesso deve ser absolvido na falta do laudo de constatação toxicológico da droga, a acusada deve ser absolvida se não há prova da materialidade do crime.

Na falta de prova segura, não há como aferir a materialidade do delito de calúnia, o que deve conduzir à ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Viradouro

Foro de Viradouro

Vara Única

Rua José Borelli, 10, Viradouro - SP - cep 14740-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Sentença nos autos sob o n. 1000398-89.2020.8.26.0660 - lauda de
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1000398-89.2020.8.26.0660

Classe - Assunto

Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz Singular - Calúnia

Querelante:

Aline Lourenço Silva

Querelado:

Tania Magali Drugovich

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PEDRO HENRIQUE ANTUNES MOTTA GOMES

Vistos e examinados os presentes autos.

Relatório dispensado nos termos do art. 81, § 3º da Lei 9.099/95.

Enfim, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. DECIDO.

O feito encontra-se em ordem. Não há preliminares a dirimir. Presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as condições da ação e os pressupostos processuais. Portanto, pertinente a análise do mérito da causa.

Cuida-se de ação penal pública, na qual a acusação imputa a prática de fato tipificado no art. 138, art. 139 e art. 140 cc. art. 141, inciso III, na forma do art. 69 do Código Penal.

Em alegações finais, a parte querelante pediu a condenação da querelada pelo crime de calúnia.

A parte querelada, por sua vez, impugnou os documentos juntados, apontando suas fragilidades, e pediu a absolvição da querelante.

O Ministério Público, em seu parecer final, reconheceu que há alta probabilidade de

que as mensagens tenham sido postadas no Facebook pela acusada, mas não há certeza cabal a respeito disso, notadamente porque não foi produzida ata notarial ou similar. Destacou que não houve direcionamento à vítima.

Em sede de audiência de instrução e julgamento, foi reconhecida a prescrição da pretensão punitiva em relação aos crimes do art. 139 e 140 do Código Penal, prosseguindo o feito pela imputação do art. 138 do Código Penal.

Passo a análise da prova oral produzida.

Ouvida em Juízo, a vítima disse que passou o dia no hospital com sua amiga; a acusada teve um relacionamento com seu pai; ela estava postando coisas no Facebook indiretamente à vítima; a vítima acessou e viu; tentou responder; as coisas foram se agravando; gerou uma vergonha e constrangimento; mexeu emocionalmente; a vítima procurou a Justiça; até hoje ela posta coisas no Facebook; a vítima disse que a acusada abortou, que foi a uma clínica de aborto; a acusada postou uma nota constando o nome da vítima no Facebook; ela disse que a vítima abortou; houve postagens posteriores à medida protetiva que a vítima obteve; a vítima proibia seu pai de falar com os filhos; a acusada chamou a depoente de caloteira e disse que foi em uma clínica abortar filho.

A testemunha LUIZ GUSTAVO COTRIN LEONE disse que tomou conhecimento de um desentendimento entre vítima e acusado pelo Facebook; a postagem estava na linha do tempo da acusada; falava algo sobre a vítima ser caloteira e havia algo sobre aborto em uma clínica em São Paulo; não se recorda bem; tempos depois do depoimento em Delegacia de Polícia, ao se pré-candidatar para vereador, a acusada entrou em uma postagem no Facebook e fez comentários chatos, dizendo que as pessoas não deveriam votar em candidatos que correram de audiência em Delegacia de Polícia; nessas publicações originais, havia comentários que envolviam família; os comentários foram postados pela página do Facebook da acusada; havia a publicação de alguns boletos; pelo que se recorda, o comentário do aborto não explicitou o nome de ninguém; “não posso falar que era para a Aline, assim, mas teve algo falando de aborto no momento da discussão das duas”.

A testemunha MILEIDE FAUSTINO GARCIA disse que tomou conhecimento sobre um entrevero entre acusada e vítima no Facebook; a acusada chamou a vítima de vagabunda, bêbada, encardida, caloteira; o boleto tinha o nome de ALINE; indagada se imputou crime, afirmou que houve muitas ofensas; a acusada nada disse sobre a vítima maltratar seu pai, esposo da acusada; sabe dizer que as ofensas foram imputadas à vítima; ficou sabendo sobre uma situação em que a acusada arremessou o carro; a acusada teve problemas com outras pessoas no Facebook; em relação ao aborto, a acusada disse que a vítima foi até São Paulo fazer aborto; tem certeza que foi a acusada que postou; a depoente não é cunhada da vítima.

LAIS BIANCA ANTONIO foi ouvida como informante, porque a vítima já processou seus pais em tempos idos; a depoente foi casada com o sobrinho da acusada; disse também que a acusada lhe contou que a vítima estava acusando-a de ter usado as redes sociais para lhe xingar; disse que a vítima estava processando a acusada; a acusada lhe disse que nem sabia do que estava acontecendo; a depoente não viu nada no Facebook da acusada; o Facebook da acusada fica sempre logada no computador; a acusada nunca acusou a vítima de ter feito aborto; a acusada já teve problemas judiciais com seu sobrinho RAFAEL por conta das redes sociais, mas a depoente aconselhou a não fazê-lo, porque acreditava que ela estava dopada; os posts eram excluídos logo em sequência.

DANIELA DOS SANTOS disse que é empregada da acusada e por esse motivo foi ouvida como informante; pode dizer, pelo que vê, que é muito difícil a acusada entrar em redes sociais, porque ela toma muito remédio e fica boa parte do tempo dormindo; a acusada nunca lhe disse que a vítima fez algum aborto; o esposo da acusada tinha acesso às redes sociais da acusada e às senhas de banco; o esposo da acusada que usava o computador da acusada; a depoente trabalha com a acusada durante o dia todo e vai embora por volta de 18 horas; a acusada dorme durante o dia e toma remédios à noite; trabalha na casa da acusada há dois anos; na época das ofensas, a depoente não trabalhava na casa; ouvia o esposo da acusada dizer que ela não tinha nada com isso e se houvesse alguma mensagem foi ele que mandou; o esposo da acusada se negou a testemunhar a favor da acusada; não tem conhecimento de entrevero recente

envolvendo acusada e vítima; sabe da existência de uma medida protetiva em favor da vítima.

JENIFER RIBEIRO DE ASSIS foi ouvida como informante por ser cunhada da acusada; a acusada nunca acusou a vítima de ter praticado aborto em São Paulo; a acusada não sabe manusear redes sociais; as senhas ficavam salvas no computador; qualquer um conseguia acessar.

Em seu interrogatório judicial, a acusada nega os fatos; acredita que é tudo mentira e há extorsão; tem quase certeza que foi o pai da vítima que fez as postagens; teve uma discussão com JENIFER no telefone; seu esposo, que até então lhe protegia, mandou levar a acusada embora; o esposo da acusada ficou conversando com a vítima; a depoente não tem conhecimento; a vítima tem vários processos contra a acusada; a situação do carro é mentira; a depoente ajudou muito a família da vítima; a vítima faz boletim de ocorrência contra todas as pessoas; tudo não passa de uma invenção;

No que toca à prova documental, constam capturas de tela de rede social Facebook exibindo publicações feitas pelo perfil "Tania Magali Drugovich" às f. 41-59.

Pois bem.

Proferi sentença determinando o arquivamento do incidente dos autos sob o n. 0000669-47.2022.8.26.0660, fundamentalmente porque ali se pretendia discutir a falsidade ideológica das capturas de tela juntadas nestes autos (já que a querelada alega que os dizeres não foram por ela proferidos), o que não pode ser objeto de incidente de falsidade, destinado a apurar falsidade material.

Entretanto, referido arquivamento não inibe a discussão sobre a qualidade da prova e o standard probatório necessário para alcançar uma condenação.

Afinal, a querelante, ofendida em sua honra, preferiu recorrer à ação criminal em detrimento da reparação civil. Assim o fazendo, submete-se ao maior rigor do processo penal, tanto em termos de procedimento, como em termos de prova. Destaco que, em matéria de direito processual penal, em que o bem jurídico ameaçado é a liberdade do acusado e especialmente quando o particular atua como substituto processual do Estado na persecução criminal (ação penal privada), é necessária estrita e intransigente atenção aos prazos e formalidades processuais, sob pena de permitir o Juízo que a ação penal se transmude em constrangimento ilegal.

E, bem analisados os elementos dos autos, concluo que não está demonstrada a materialidade do delito.

Sobre o standard probatório adequado à presunção de inocência, ensina a doutrina: O segundo enunciado que compõe o standard de prova apresentada trata do grau exigido para as provas que dão suporte aos fatos alegados pela defesa. Uma hipótese defensiva que encontre confirmação em um segmento da prova, ainda que em menor intensidade que o aval dado pelas provas diversas em favor da hipótese da acusação, deve ser suficiente para levar ao reconhecimento de que a imputação não está provada e, havendo dúvida, o acusado será absolvido. Todavia, esse juízo deve ser realizado com relação às provas existentes e às hipóteses fáticas efetivamente aduzidas pela defesa (p. ex.: tendo invocado um alibi ou alegado estado de necessidade). Novamente, não há sentido em exigir que não existam provas que excluam "hipóteses plausíveis explicativas dos mesmos dados". O que pode levar à absolvição são provas efetivamente existentes, que confirmam uma hipótese formulada pela defesa, ainda que em menor intensidade. É inviável exigir que o juiz, diante de todas as teses passíveis de serem alegadas pelo defensor, fique especulando se alguma delas poderia ter ocorrido no caso. Por outro lado, limitar as explicações probatórias às alegações defensivas efetivamente formuladas torna desnecessária a ressalva de "hipóteses ad hoc". Ou se trata de uma tese concretamente posta pela defesa, cabendo avaliar se restou confirmada em algum grau, ou não é preciso que o juiz fique fazendo lucubrações fantásticas ou formulando hipóteses cerebrinas (BADARÓ, Gustavo Henrique. Epistemologia judiciária e prova penal, Thomson Reuters Revista dos Tribunais, São Paulo, 2019, item 3.6.2.4)

Já o standard probatório exigido para a condenação e a distribuição do ônus da prova no processo penal informam que a não produção de meios de prova inequivocamente disponíveis para corroborar o depoimento da vítima e lhe conferir coesão e compatibilidade com os demais elementos de prova é ônus que deve recair

sobre a acusação e não deve ser suportado pelo acusado.

Com base no princípio do livre convencimento motivado, estampado no art. 155 do Código de Processo Penal, o juiz aprecia a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a houver produzido, e explicita as razões do seu convencimento, sem que exista, na maior parte dos casos, prova tarifada. Neste contexto, a captura de tela de dispositivo eletrônico somente pode servir como prova no processo penal se a parte adversa não se opor à sua forma e ao seu conteúdo. Caso isto ocorra, desnuda-se a fragilidade da prova, uma vez que cuida-se de arquivo de imagem estática facilmente manipulável sem meios de verificação da integridade e autenticidade do seu conteúdo.

No caso dos autos, isto é especialmente grave, pois não se trata de simples captura de tela. Como se vê das imagens de f. 41-50, foram feitas capturas de tela, referidas imagens foram impressas e referidas impressões foram digitalizadas. Isto revela a fragilidade da prova, o que não permite ao julgador atribuir-lhe relevante valor probatório.

Na espécie, sequer foi apresentada a URL (endereço de rede) das publicações, de modo que, pela prova juntada, é verdadeiramente impossível aferir se as mensagens foram realmente postadas no perfil da rede social de titularidade da querelada e não em qualquer outro perfil dissimulado, com uso de nome e fotografia alheios. Para fazer prova segura de dispositivo eletrônico no processo penal, deveria a parte ter apresentado meio confiável de prova, a exemplo de ata notarial, prova preservada pela tecnologia de blockchain ou qualquer instrumento de preservação de provas digitais que permita aferir a integridade e autenticidade das mensagens (a exemplo do serviço Verifact).

Ora, o ônus probatório no processo, ainda que penal, deve ser tão intenso quando a capacidade da parte de dele se desincumbir. Por conclusão, exige-se um ônus probatório menor naqueles crimes ocultos, cometidos na clandestinidade, como um estupro ou roubo em local ermo; por outro lado, exige-se um rigor probatório maior naqueles crimes cometidos em público ou à vista de testemunhas. Não sem razão, dispõe o art. 6º, inciso III do Código de Processo Penal determina: “Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá: (...) colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias”.

No AREsp n. 1940381/AL (rel. Min. RIBEIRO DANTAS, j. 14/12/2021), o Superior Tribunal de Justiça tratou da teoria da perda de uma chance probatória aplicada ao processo penal. Em referido acórdão, explicou-se que “quando o Ministério Público se satisfaz em produzir o mínimo de prova possível – por exemplo, arrolando como testemunhas somente os policiais que prenderam o réu em flagrante –, é na prática tirada da defesa a possibilidade de questionar a denúncia. Por isso, a acusação não pode deixar de realmente investigar o caso, transferindo à defesa o ônus de fazê-lo. Ao contrário, a polícia e o Ministério Público devem buscar o que os autores chamam de comprovação externa do delito: a prova que, sem guardar relação de dependência com a narrativa montada pela instituição estatal, seja capaz de corroborá-la”.

Na doutrina:

Nas hipóteses em que o Estado se omite e deixa de produzir provas que estavam ao seu alcance, julgando suficientes aqueles elementos que já estão à sua disposição, o acusado perde a chance – com a não produção (desistência, não requerimento, inviabilidade, ausência de produção no momento do fato etc.) –, de que a sua inocência seja afastada (ou não) de boa-fé. Ou seja, sua expectativa foi destruída (ROSA, Alexandre Moraes da; RUDOLFO, Fernanda Mambrini. A teoria da perda de uma chance probatória aplicada ao processo penal. Revista Brasileira de Direito, v. 13, n. 3, 2017, p. 462).

Assim, conclui que, havendo outras provas possíveis para auxiliar o esclarecimento dos fatos, é ônus da Acusação produzi-las ou justificar a inviabilidade de sua produção. Rememore-se que é ônus da Acusação desfazer a presunção de não culpabilidade. É inadmissível que, existindo uma prova capaz de inocentar o acusado – diretamente relacionada à narrativa da denúncia, sendo sua existência de conhecimento da Acusação e sua produção razoável – o Ministério Público ou

querelante opte por não produzi-la, a despeito dos esclarecimentos que a prova poderia trazer. Se não o faz, não se pode relativizar e reduzir o ônus probatório da Acusação em prejuízo do acusado.

Não se cuida de mero formalismo ou exigência cosmética. Reforço, como tenho reforçado em outras oportunidades, que o Poder Judiciário tem que estar a par do estado da arte da tecnologia. Nestes tempos em que aplicações de alta tecnologia para truçagem são razoavelmente acessíveis ao usuário comum (a exemplo dos vídeos com manipulação por tecnologia deepfake) e de disseminação rotineira de desinformação, a integridade da prova digital é tema da maior importância e atenção.

Para a materialidade do crime digital, não há como prescindir da análise dos metadados para a aferição da integridade e autenticidade de publicação em rede social; do contrário, seria o equivalente a tentar demonstrar a materialidade do crime de tráfico de maconha com uma fotografia de uma erva. E, da mesma forma que o traficante confesso deve ser absolvido na falta do laudo de constatação toxicológico da droga, a acusada deve ser absolvida se não há prova da materialidade do crime.

Na falta de prova segura, não há como aferir a materialidade do delito de calúnia, o que deve conduzir à absolvição.

Reitero, uma vez mais, que esta solução decorre da opção da parte ofendida em sua honra em propor ação penal e não ação de responsabilidade civil, pois é razoável supor que no processo civil – orientado pelo livre convencimento fundamentado do art. 371 do Código de Processo Civil e pela ideia de prova prevalente, assim compreendida aquela que dá por provada determinada afirmação se houver mais de 50% de chance que os fatos tenham ocorrido da maneira sustentada na acusação – a prova aqui produzida pudesse vicejar e sustentasse a pretensão reparatória. Ocorre que esta ideia é insuficiente para o processo penal, que trabalha com a ideia de conclusão condenatória além de qualquer dúvida razoável (reasonable doubt) (doutrina estadunidense) ou verdade processual hegemônica (doutrina espanhola).

Por fim, destaco o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que incidem honorários advocatícios sucumbenciais na ação penal privada, pois “[a] jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser possível a condenação do vencido na ação penal privada ao pagamento de honorários sucumbenciais, o que resulta da aplicação da analogia e dos princípios gerais do Direito, consoante previsto no art. 3º do Código de Processo Penal.

Precedentes” (STJ, AgRg no REsp 1.417.694, Quinta Turma, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, j. 19/04/2018).

Ante o fundamentado e por tudo mais que dos autos consta, resolvo o mérito da ação penal e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva contida na denúncia para ABSOLVER, na forma do art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, o acusado TANIA MAGALI DRUGOVICH da imputação do cometimento de crime descrito no art. 138 cc. art. 141, inciso III, do Código Penal.

Comunique(m)-se ao(s) ofendido(s) a presente sentença, na forma do art. 201, § 2º do Código de Processo Penal.

Condeno a querelante ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais, a partir da ponderação dos elementos do art. 85 do Código de Processo Civil e considerando o disposto no § 8º do mesmo dispositivo, fixo em R\$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento e juros a partir do trânsito em julgado.

Cientifique-se o Ministério Público.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diligências necessárias. Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo e dê-se baixa.

Viradouro, 27 de outubro de 2022.

PEDRO HENRIQUE ANTUNES MOTTA GOMES

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA